

대전고등법원 2023. 5. 31. 선고 2022나16053 판결

[손해배상(기)]

대 전 고 등 법 원

제 3 민 사 부

판 결

사건	2022나16053 손해배상(기)
원고,피항소인	A 소송대리인 법무법인 청연, 담당변호사 박연진, 이정근
피고,항소인	주식회사 C 소송대리인 변호사 장철희 소송복대리인 변호사 전진주
제1심판결	대전지방법원 2022. 10. 26. 선고 2021가합104003 판결
변론종결	2023. 4. 5.
판결선고	2023. 5. 31.

주 문

1. 제1심판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고는 제1심 공동피고 주식회사 B과 공동하여 원고에게 137,937,430원 및 그중 22,000,000원에 대하여는 2019. 2. 27.부터 2020. 1. 31.까지 연 5%의, 115,937,430원에 대하여는 2019. 2. 27.부터 2023. 5. 31.까지 연 5%의, 각 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

2. 소송총비용 중 60%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

3. 제1의 가.항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지 및 항 소 취 지

[청구취지]

피고는 제1심 공동피고 주식회사 B'과 공동하여 원고에게 364,462,267원 및 그중 142,000,000원에 대하여는 2019. 2. 27.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을, 222,462,267원에 대하여는 2019. 2. 27.부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서부분 송달일까지 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.

[항소취지]

제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

이 유

1. 기초사실

가. 제1심 공동피고 주식회사 B(이하 'B'이라 한다)은 경기 가평군 D에 있는 숙박시설 'E'(이하 '이 사건 펜션'이라 한다)을 운영하는 법인이다.

나. 원고는 2019. 2. 27. 18:00 이 사건 펜션 내 송어낚시 체험 풀장에서 낚싯대를 투척하다가 미끄러져 풀장 안으로 빠졌다(이하 '이 사건 사고'라 한다). 원고는 같은 날 이 사건 펜션 인근 F병원 응급실에서 진료를 받았다.

다. 원고는 이 사건 사고 발생 다음 날인 2019. 2. 28.부터 3. 27.까지 28일간 G병원에 입원하여 치료를 받았는데, 주 상병 "Fracture of lower end of tibia with fracture of fibula(any part)", 보조상병 "발목 및 발부위에서의 인대 파열" 진단을 받았다(이하 '이 사건 상해'라 한다).

라. B은 2019. 6. 27. H, I, J 등 3인(이하 'H 등 3인'이라 한다)과 영업권리 일체를 양도.양수한다는 내용의 '양도.양수서'를 작성하였고, H 등 3인은 같은 날 이 사건 펜션의 영업자지위승계신고서를 가평군수에게 제출한 뒤 이 사건 펜션의 상호를 'K'으로 변경하여 운영하였다.

마. H 등 3인은 2019. 9. 19. 피고와 영업권리 일체를 양도.양수한다는 내용의 '양도.양수서'를 작성하였고, 피고는 같은 날 이 사건 펜션의 영업자지위승계신고서를 가평군수에게 제출한 뒤 이 사건 펜션의 상호를 'L'으로 변경하여 운영 중이다.

【인정근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 7 내지 9, 13, 28호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 내지 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. B의 불법행위로 이 사건 사고가 발생하였으므로 B은 원고에게 이 사건 사고로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있고, 피고는 B의 영업을 양수하여 상호를 계속 사용하였으므로 상법 제42조에 따라 원고의 B에 대한 손해배상채권을 B과 공동하여 변제할 책임이 있다.

나. 원고가 입은 손해는 치료비 180,212,200원(= 기왕치료비 9,712,200원 + 향후치료비 170,500,000원), 일실수입 148,155,193원, 개호비 16,094,874원(= 기왕개호비 3,326,298원 + 향후개호비 12,768,576원), 위자료 20,000,000원 등 합계 364,462,267원이므로, 피고는 B과 공동하여 원고에게 위 364,462,267원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 판단

가. B의 손해배상책임

B은 이 사건 펜션 송어낚시 체험 풀장의 운영자로서 안전관리자를 두거나, 이용자들이 풀장에 빠지지 않도록 안전설비를 갖추고 이용자들에게 안전사항에 관하여 고지하는 등의 주의의무가 있음에도 이를 이행하지 아니한 과실이 있고, 이로 인하여 원고가 이 사건 펜션의 송어낚시 체험 풀장에서 미끄러져 이 사건 상해를 입은 사실은 앞서 본 바와 같거나 앞서 든 증거들에 의하여 인정할 수 있다. 그렇다면 B은 민법 제750조에 따라 원고에게 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

나. 피고의 손해배상책임

1) 관련 법리

가) 상법 제42조 제1항은 영업양수인이 양도인의 상호를 계속 사용하는 경우에는 양도인의 영업으로 인한 제3자의 채권에 대하여 양수인도 변제할 책임이 있다고 규정하고 있고, 이때 양도인의 영업으로 인한 채무란, 영업상의 활동에 관하여 발생한 채무를 말한다(대법원 2002. 6. 28. 선고 2000다5862 판결 등 참조).

나) 영업으로 인하여 발생한 채무란 영업상의 활동에 관하여 발생한 모든 채무를 말한다고 하여야 할 것이므로 불법행위로 인한 손해배상채무도 이에 포함된다고 보아야 할 것이다(대법원 1989. 3. 28. 선고 88다카12100 판결 등 참조).

다) 상법 제42조 제1항이 상호를 계속 사용하는 영업양수인에게 양도인의 영업으로 인한 채무에 대하여도 변제할 책임이 있다고 규정하고 있는 것은, 일반적으로 채무자의 영업상 신용은 채무자의 영업재산에 의하여 실질적으로 담보되는 것이 대부분인데 채무가 승계되지 아니함에도 상호를 계속 사용함으로써 영업양도의 사실 또는 영업양도에도 불구하고 채무의 승계가 이루어지지 않은 사실이 대외적으로 판명되기 어렵게 되어 채권자에게 채권 추구의 기회를 상실시키는 경우 양수인에게도 변제의 책임을 지우기 위한 것이므로, 영업양도인이 사용하던 상호와 양수인이 사용하는 상호가 동일할 것까지는 없고 다만 전후의 상호가 주요 부분에 있어서 공통되기만 하면 상호를 계속 사용한다고 보아야 한다(대법원 1998. 4. 14. 선고 96다8826 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

앞서 든 증거들, 갑 제15, 18, 19호증의 각 기재 내지 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사정을 위 법리에 비추어 보면, 피고는 B의 영업을 양수한 뒤 상호를 계속 사용하였음이 인정되므로 원고의 B에 대한 손해배상채권에 대하여 B과 공동하여 변제할 책임이 있다.

가) 순차적 영업양도

(1) B은 2019. 6. 27. H 등 3인에게 '양도.양수서'를 작성해주었는데, 위 서면에는 이 사건 펜션의 영업허가(신고)에 대한 영업권리 일체를 양도.양수한다는 내용이 포함되어 있다. 2019. 6. 27. 기준으로 이 사건 펜션의 국민건강보험 가입자들 중 B의 대표이사 P를 제외한 나머지 직원들(Q, R, S, T, U, V, W, X)은 위 영업양도 후에도 이 사건 펜션에서 계속 근무하였다.

(2) H 등 3인은 2019. 9. 19. 피고에게 '양도.양수서'를 작성해주었는데, 위 서면에도 역시 이 사건 펜션의 영업허가(신고)에 대한 영업권리 일체를 양도.양수한다는 내용이 포함되어 있다. 2019. 9. 19. 기준으로 이 사건 펜션의 국민건강보험 가입자들 중 H, I을 제외한 나머지 직원들(Q, R, S, T, V, W, X)은 위 영업양도 후에도 이 사건 펜션에서 계속 근무하였다.

나) 상호의 계속 사용

(1) B이 이 사건 펜션을 운영하면서 사용한 상호는 'E', H 등 3인이 사용한 상호는 'K', 피고가 사용한 상호는 'L'이다. 'Y', '풀빌라', '펜션' 등의 단어는 숙박시설을 나타내는 용어이므로, 이 사건 펜션을 다른 숙박업소와 차별 짓게 하는 단어는 'Z'이라고 볼 수 있는데, 피고는 B이 사용하던 'Z'이라는 단어를 H 등 3인을 거쳐 그대로 사용하고 있어 주요 부분에서 공통된다.

(2) 피고는 홈페이지에서도 과거 사용하던 상호인 'K'를 그대로 혼용하여 사용하고 있고, 'E'이라는 상호를 사용하여 작성된 공지사항도 삭제하지 않고 그대로 노출되도록 하고 있다.

다) 영업으로 인한 채무의 존재

영업으로 인하여 발생한 채무란 영업상의 활동에 관하여 발생한 모든 채무를 말하고 불법행위로 인한 손해배상채무도 이에 포함되므로, 이 사건 사고로 인한 B의 원고에 대한 손해배상채무도 영업으로 인한 채무에 포함된다.

다. 손해배상책임의 제한

민법상의 과실상계 제도는 채권자가 신의칙상 요구되는 주의를 다하지 아니한 경우 공평의 원칙에 따라 손해의 발생에 관한 채권자의 그와 같은 부주의를 참작하게 하려는 것이므로 단순한 부주의라도 그로 말미암아 손해가 발생하거나 확대된 원인을 이루었다면 피해자에게 과실이 있는 것으로 보아 과실상계를 할 수 있고, 손해배상의무자가 피해자의 과실에 관하여 주장하지 않는 경우에도 소송자료에 의하여 피해자의 과실이 인정되는 경우에는 이를 법원이 직권으로 심리.판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 26. 선고 2010다37479 판결 등 참조).

앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 풀장 주위는 물이 튀거나 흐르는 등 미끄러운 상황일 것이므로 원고는 미끄러지지 않도록 주의를 기울였어야 하는 점, 위 풀장에는 안전줄에 “추락위험” 등이 기재된 풋말이 설치되어 있었는데 원고는 위 경고문구에도 불구하고 낚싯대를 투척하기 위하여 부주의하게 안전줄 방면으로 몸을 기대어 이 사건 사고가 발생한 것으로 보이는 점 등을 종합하면 원고에게도 이 사건 사고 발생의 원인이 되는 과실이 존재한다고 봄이 상당하고, 이러한 점에다가 이 사건 사고의 발생 경위 등 이 사건 변론에 나타난 제반 사정을 고려하면, 손해의 공평하고 타당한 분담을 지도 원리로 하는 손해배상제도의 이념에 따라 B의 책임을 60%로 제한함이 타당하다.

라. 손해배상책임의 범위

이 법원이 이 부분에 관하여 적을 이유는 아래와 같이 그 일부를 고치는 것 외에는 제1심판결의 해당 부분(제1심판결 제5면 제11행부터 제12면 제9행까지) 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 따라 이를 그대로 인용한다.

○ 제6면 제17행의 “원 미만 버림” 다음에 “, 이하 같다”를 추가한다.

○ 제7면 제14행의 “이 법원의”를 “제1심 법원의”로 고친다.

○ 제9면 표 아래 제1, 2행을 아래와 같이 고친다.

『바) 피고의 책임 제한에 따른 손해배상액: 74,313,850원

74,313,850원(= 123,856,418원 × 60%)』

○ 제10면 제5~8행과 그 아래 표를 다음과 같이 고친다.

『이 사건 변론종결일까지 위 각 수술비 및 재활치료비용을 지출하였다고 볼 증거가 없으므로, 이 사건 변론종결일 다음 날인 2023. 4. 6. 이를 지출하는 것으로 보고 이 사건 사고 당시 현가로 계산하면 아래 표 기재와 같이 71,327,100원 (= 5,812,800원 + 4,567,200원 + 5,812,800원 + 55,134,300원)이다.

종류:	인공관절치환술 내지 관절유합술	수명(년):	1	종류:	관절성형술	수명(년):	1
단가:	7,000,000원	수명(월):	0	단가:	5,500,000원	수명(월):	0
최초필요일:	2023.04.06	수치합계:	0.8304	최초필요일:	2023.04.06	수치합계:	0.8304
필요최종일:	2023.04.06	비용총액:	5,812,800원	필요최종일:	2023.04.06	비용총액:	4,567,200원
순번	필요일시	월수	호프만 수치	순번	필요일시	월수	호프만 수치
1	2023-04-06	48	0.8304	1	2023-04-06	48	0.8304
종류:	성형수술	수명(년):	1	종류:	재활치료비	수명(년):	1
단가:	7,000,000원	수명(월):	0	단가:	7,800,000원	수명(월):	0
최초필요일:	2023.04.06	수치합계:	0.8304	최초필요일:	2023.04.06	수치합계:	7.0683
필요최종일:	2023.04.06	비용총액:	5,812,800원	필요최종일:	2033.04.05	비용총액:	55,134,300원
순번	필요일시	월수	호프만 수치	순번	필요일시	월수	호프만 수치
1	2023-04-06	42	0.8304	1	2023-04-06	48	0.8304
				2	2024-04-06	60	0.7973
				3	2025-04-06	72	0.7667
				4	2026-04-06	84	0.7383
				5	2027-04-06	96	0.7121
				6	2028-04-06	108	0.6876
				7	2029-04-06	120	0.6647
				8	2030-04-06	132	0.6434
				9	2031-04-06	144	0.6233
				10	2032-04-06	156	0.6045

』

○ 제11면 제13행부터 제17행까지를 아래와 같이 고친다.

『라) 계산: 81,039,300원

소극적 손해의 합계는 81,039,300원(= 기왕치료비 9,712,200원 + 향후치료비 71,327,100원)이다.

마) 피고의 책임 제한에 따른 손해배상액: 48,623,580원

48,623,580원(= 81,039,300원 × 60%)』

○ 제12면 제1행부터 제9행까지를 아래와 같이 고친다.

『그렇다면 피고는 B과 공동하여 원고에게 불법행위로 인한 손해배상으로 137,937,430원(= 소극적 손해

74,313,850원 + 적극적 손해 48,623,580원 + 위자료 15,000,000원) 및 그중 22,000,000원(원고가 소장에서

청구한 적극적 손해 22,000,000원)²에 대하여는 불법행위일인 2019. 2. 27.부터 이 사건 소장 부분 송달일인

2020. 1. 31.까지 민법이 정한 연 5%의, 115,937,430원에 대하여는 불법행위일인 2019. 2. 27.부터 피고가 그 이

행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2023. 5. 31.까지 민법이

정한 연 5%의, 각 그다음 날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연

손해금을 지급할 의무가 있다.』

4. 결론

그렇다면 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 기각하
여야 한다. 제1심판결은 이와 일부 결론을 달리하므로, 피고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결을 주문과 같이 변경한
다.

1 제1심 공동피고 주식회사 B에 대한 부분은 원고와 위 피고가 제1심판결에 대하여 항소하지 아니하여 분리.확정되었다.

2 손해 3분설에 따라 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료(정신적 손해)는 각 별개의 소송물이므로 소장에서 청구한 금액 중 전부 인용되는 부분인 적극적 손해 22,000,000원에 한하여 소장 부분 송달일 다음 날부터 소송촉진 등에 관한 특례법상 이율을 적용하기로 한다.

